

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

[기출][2][2008-2]쟁의행위 기간 중 사용자의 채용 제한의 원칙, 필수공익사업의 특례, 위반 시 쟁점

《【문제2】 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용제한에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용 제한의 원칙, 필수공익사업의 특례, 위반 시 쟁점

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위는 근로조건의 유지·개선이라는 정당한 목적을 달성하기 위한 근로자의 헌법상 기본권 행사이다. 그러나, 쟁의행위가 현실적으로 사업 운영을 중단시킬 경우, 사용자가 이를 무력화하기 위해 신규 근로자를 채용하거나 외부 인력을 투입한다면 쟁의행위 자체가 형해화될 우려가 있다. 이에 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용과 도급을 엄격히 제한하고 있다. 이하에서는 관련 법령과 판례를 토대로 사용자의 채용 제한 원칙, 특례, 위반 시 제재에 관하여 논한다.

II. 쟁의행위 중 사용자의 채용 제한 원칙

1. 당해 사업과 관계없는 자의 채용 또는 대체 금지

(1) 규정 내용

- 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 당해 사업과 관계없는 자를 채용하거나 대체하는 행위를 금지한다.

(2) 규정의 취지

- 근로자의 쟁의행위 실효성을 보장하기 위함이다. 만약 사용자가 외부 인력을 투입한다면 단체행동권은 무력화될 수 있다.

(3) 당해 사업과 관계없는 자의 범위

- 판례는 당해 사업의 소속 근로자가 아닌 자를 의미한다고 본다. 외부에서 신규 채용된 근로자, 용역·파견업체 근로자가 이에 해당한다.

(4) 당해 사업과 관계있는 자의 범위

- 원칙적으로 기존 근로자와 관리자, 평소 근로계약 관계에 있는 자이다. 다만, 사용자가 쟁의행위 직전에 신규 채용한 자까지 포함되는지 여부는 논란이 있으나, 판례는 쟁의행위 개시 전에 근로계약관계가 확립된 경우에는 관계 있는 자로 본다.

2. 쟁의행위로 중단된 업무의 도급 또는 하도급 금지

(1) 규정 내용

- 노조법 제43조 제2항은 사용자가 쟁의행위로 중단된 업무를 도급이나 하도급을 통해 처리하는 것을 금지한다.

(2) 규정의 취지

- 사용자가 외부 계약을 통해 손쉽게 업무를 대체하면 쟁의행위의 실효성이 훼손되므로 이를 차단하기 위함이다. 특히 간접적 형태의 대체근로를 방지하는 기능을 가진다.

III. 필수공익사업의 특례

1. 채용 및 도급 제한의 예외

(1) 적용 대상

- 노조법 제71조는 필수공익사업의 경우 채용 및 도급 제한의 예외를 규정한다.

(2) 필수공익사업의 정의

- 국민의 일상생활이나 국가경제에 중대한 영향을 미치는 사업으로, 노조법 시행령 제12조에서 철도·병원·전기·가스·수도 등 공공서비스가 대표적이다.

2. 대체 허용 범위의 제한

(1) 제한 규정

- 필수공익사업이라 하더라도 대체는 쟁의행위로 인한 중단을 최소한의 범위에서만 허용한다. 즉, 국민의 생명·안전보호 및 필수 서비스 유지 목적에 국한된다.

(2) 취지

- 단결권 보장과 국민 생활 보호 간의 균형을 도모하기 위함이다. 따라서 전면적 대체는 허용되지 않고 필수유지업무에 한정된다.

IV. 법규 위반 시 제재 및 관련 쟁점

1. 위반 시 제재

- 노조법 제91조는 제43조에 위반하여 채용하거나 대체한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정한다. 형사처벌 외에도 부당노동행위로서 노동위원회의 구제명령 대상이 될 수 있다.

2. 관련 쟁점

(1) 정당한 쟁의행위 여부

- 만약 쟁의행위가 정당성을 상실한 경우, 사용자의 채용 제한 위반 여부는 문제되지 않는다. 즉, 쟁의행위의 적법성을 전제로 한 보호 규정이다.

(2) 원청의 대체근로

- 하도급 구조에서 원청이 직접 대체근로를 투입하는 경우, 당해 사업의 범위에 포함되는지 논란이 있다. 판례는 실질적 사용자성을 기준으로 판단한다.

(3) 당해 사업의 해석

- 당해 사업은 단위 사업장에 국한되는 것이 아니라 기업 전체 차원에서 판단해야 한다는 견해가 유력하다. 그러나, 판례는 구체적 사안별로 기능적·조직적 관련성을 고려하여 판단한다.

V. 결론

- 노조법은 쟁의행위 기간 동안 사용자가 신규 근로자를 채용하거나 도급을 통해 업무를 대체하는 행위를 금지하여 쟁의행위의 실효성을 보장하고 있다. 이는 근로자의 단결권을 실질적으로 보장하기 위한 장치로서, 다만 국민 생활과 직결되는 필수공익사업에서는 제한적 예외를 두고 있다. 사용자가 이를 위반할 경우 형사처벌 및 부당노동행위 책임을 부담한다. 따라서 사용자는 쟁의행위 기간 중 채용 및 도급과 관련하여 법적 한계를 철저히 준수해야 하며, 근로자와 노조 역시 쟁의행위의 정당성을 유지하는 방식으로 권리를 행사해야 할 것이다.